

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7121/2552

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นางดวงฤดี อุบลแสน

โจทก์ร่วม

นายอรรถพล วัชรรัตนพล

จำเลย

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4, มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, มาตรา 62

พฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุให้สงสัยตามสมควรว่า เป็นไปได้ที่โจทก์ร่วมวาดแม่แบบก่อนการแกะแบบโดยลอกแบบส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมาจากการประติมากรรมนางรำคู่ขึ้นหนึ่งที่ปรากฏอยู่ที่เสาของโบราณปราสาทบายน จากนั้นจึงทำบล็อกและแกะแบบต่อไปตามลำดับ หรือไม่ก็อาจนำลายที่ลอกจากงานศิลปะที่พบเห็นได้ทั่วไป ทั้งที่เป็นศิลปะไทยหรือศิลปะขอมซึ่งสามารถเขียนลอกลายกันได้อย่างง่ายดายมาเขียนลอกลงไปในส่วนที่เป็นรายละเอียดของงานประติมากรรมนางรำคู่ที่ปรากฏอยู่ที่เสาของโบราณสถานปราสาทบายนอีกเพียงเล็กน้อย ซึ่งหากลักษณะการสร้างงานของโจทก์ร่วมเป็นเช่นนั้น ก็ไม่อาจถือได้ว่าการสร้างงานประติมากรรมนางรำคู่ของโจทก์ร่วมเป็นการสร้างงานที่มีความคิดริเริ่มด้วยตนเองหรือใช้ความวิริยะอุตสาหะที่เพียงพอแม้แต่เพียงขั้นเล็กน้อย

แม้การทำซ้ำหรือดัดแปลงจากงานประติมากรรมนางรำคู่ตามโบราณสถานจะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอยู่บ้าง แต่ก็มีความวิริยะอุตสาหะในการทำซ้ำหรือดัดแปลง มิอาจถือเป็นความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานถึงขนาดจะได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามความหมายของกฎหมาย ดังนั้น ไม่ว่าจำเลยจะได้ขายงานที่ทำ

ซ้ำหรือดัดแปลงจากงานประติมากรรมนางรำคู่ตามวัตถุพยานของโจทก์ร่วมหรือไม่
ก็ตามการกระทำของจำเลยย่อมไม่อาจเป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วม

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
มาตรา 4, 6, 8, 15, 27, 31, 70, 75 และ 76 ให้ "งานผนังดินเผาหุ่นดำ ชูด นางรำ
คู่" ของกลางตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และสั่งจ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่ง
หนึ่งให้แก่โจทก์ร่วมซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางดวงฤดี อุบลแสน ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาต

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษา
ว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4, 6 วรรคหนึ่ง,
31 (1), 70 วรรคสอง, 75 และ 76 ลงโทษจำคุก 3 เดือน และปรับ 60,000 บาท
โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 ให้งาน
หมาย วจ. 1 ของกลางที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตกเป็นของโจทก์ร่วมเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
จ่ายค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่โจทก์ร่วมซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "มี ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่า งานประติมากรรมผนังดินเผาหุ่นดำ ชุด นางรำคู่ ตามฟ้อง ตามวัตถุพยานหมาย วจร. 2 ซึ่งตรงกับตามสำเนารูปถ่ายแผ่นที่ 7 คืองาน รูป นั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ คดีนี้เมื่อ จำเลยโต้แย้งว่างานประติมากรรม นางรำคู่ตามวัตถุพยานหมาย วจร. 2 นั้น ทำซ้ำ หรือดัดแปลงจากงานศิลปะขอมที่มีมานานแล้ว พบเห็นได้ตามเสาต่าง ๆ ของ ปราสาทบายน ตามปราสาทต่าง ๆ ในราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นพัน ๆ ต้น รัฐบาลของ ราชอาณาจักรกัมพูชาส่งเสริมให้ประชาชนเรียนและแกะสลักขาย มีชาวบ้านแกะสลัก ขายมากมาย ซื้อมากันมานานกว่า 50 ถึง 60 ปี ตลอดทางตั้งแต่เมืองปอยเปตถึง เมืองเสียมเรียบ อันเป็นการโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โจทก์จึงไม่ได้ ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ว่างานที่มีการฟ้องร้องในคดีนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ งานดังกล่าว โจทก์ยังต้องมีภาระการพิสูจน์ให้ได้ความชัดเจนปราศจากข้อสงสัย ว่า งานประติมากรรมผนังดินเผาหุ่นดำ ชุดนางรำคู่ ตามฟ้อง ตามวัตถุพยานหมาย วจร. 2 เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งเกี่ยวกับปัญหาข้อ นี้ แม้โจทก์ไม่จำเป็นต้องนำสืบให้ได้ความว่างงานสร้างสรรค์ของโจทก์ร่วมเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะงานสร้างสรรค์ที่จะได้ลิขสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ทำขึ้นใหม่ อย่างงานที่จะพึงได้รับสิทธิบัตร แต่โจทก์ก็ต้องนำสืบให้ได้ความชัดเจนว่าโจทก์ร่วม ได้สร้างสรรค์งานด้วยตนเองโดยไม่ได้เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลง ตามความหมาย ของการทำซ้ำหรือดัดแปลงที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กล่าวคือ ไม่ได้ทำซ้ำโดยคัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์จากต้นฉบับหรือจากสำเนาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ได้ดัดแปลงโดยการทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือ จำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แต่โจทก์และ

โจทก์ร่วมมีลำพังเพียงโจทก์ร่วมมาเป็นพยานเบิกความลอย ๆ ถึงการเริ่มสร้างงานดังกล่าวว่า โจทก์ร่วมเป็นผู้คิดและสร้างสรรค์งานประติมากรรมพิพาทด้วยตนเอง โดยการออกแบบงานประติมากรรมให้มีรูปแบบ เอกลักษณ์ สัดส่วน รูปทรง ลวดลายใหม่ แตกต่างจากงานขอมโบราณรูปนางอัปสรหรืออัปสร นำความเป็นพื้นบ้านของตนซึ่งเป็นงานดินเผาผ่านเกวียนมาเป็นจุดเด่นสร้างงานขึ้นมาจากแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจ โดยที่โจทก์ร่วมไม่เคยเห็นงานประติมากรรมที่ราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อน งานดังกล่าวจึงมีรูปแบบที่สวยงามดัดแปลงลวดลายผสมผสานกับลายกนกบ้าง ลายไทยอื่น ๆ บ้าง เกิดเป็นงานขึ้นมาใหม่ ทำการวาดแบบและแกะแบบลงบนดินน้ำมัน ส่วนจำเลยมีจำเลยมาเบิกความปฏิเสธว่า โจทก์ร่วมไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานประติมากรรมดินเผานางรำคู่ ตามวัตถุประสงค์พยานหมาย จ. 2 เพราะทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบมาจากงานประติมากรรมที่ปรากฏตามเสาบายนที่มีเป็นพื้น ๆ ต้นตามปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชา งานตามวัตถุประสงค์พยานหมาย จ. 1 ที่โจทก์ร่วมกล่าวหาว่าจำเลยเสนอขายโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นงานที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของงานตามวัตถุประสงค์พยานหมาย จ. 2 นั้น จำเลยซื้อจากราชาอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อประดับร้าน ไม่ได้มีไว้ขาย โดยมีเพียงชิ้นเดียวและแขวนไว้อยู่ที่กึ่งกลางฝาผนังของร้านด้านบนสุด ไม่สามารถหยิบถึงได้ง่าย นอกจากนี้จำเลยยังมีรูปถ่ายและสำเนารูปถ่ายของงานประติมากรรมนางรำคู่ตามเสาต่าง ๆ ของโบราณสถานปราสาทบายนรวม 16 รูป สำเนาหนังสือนครวัดตามหานครธม ของพิษณุ สำเนาหนังสือประติมากรรมขอม ของศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศเรียงเรียงจากบทความของศาสตราจารย์ซอง ซึ่งในรูปประกอบท้ายเล่มรูปที่ 114 เป็นสำเนารูปถ่ายงานประติมากรรมนางอัปสรพ่อนรำบนฐานเสาระเบียงชั้นนอกของปราสาทบายน ศิลปะขอมแบบบายน สำเนาหนังสือนิราศนครวัด ของสมเด็จพระยาจักราชราชานุภาพ และสำเนารูปถ่ายประติมากรรม นางรำคู่ ที่ถ่ายจากปราสาทบายนในราชอาณาจักรกัมพูชาจากหนังสือชื่อ "ANGKOR" ได้ภาพมีคำว่า "AT THE

BAYON" ซึ่งจากรูปภาพจำนวนหลายรูปที่ปรากฏจากพยานหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น แสดงว่าประติมากรรมภาพนางรำคู่ที่เรียกว่านางอัปสรหรืออัปสราหรือ Apsaras เป็นงานประติมากรรมที่ปรากฏอยู่มากมายมาหลายร้อยปีตามเสาหรือผนังของปราสาทต่าง ๆ ที่เป็นศิลปะขอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทที่อยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชา ลักษณะประติมากรรมต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะทั้งเหมือนกันและคล้ายกัน ประติมากรรมที่มีลักษณะที่คล้ายกันนั้นล้วนมีสาระสำคัญเหมือนกันโดยมีโครงร่างเดียวกัน เพียงแตกต่างกันในรายละเอียดหรือสัดส่วน ซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นเพราะการสร้างสร้งงานทำขึ้นโดยช่างต่างคนกัน หรือสร้างสร้งงานต่างช่วงเวลากัน ความเก่าแก่ของรูปและการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาก็ทำให้รูปภาพมีลักษณะที่ต่างกันในรายละเอียด ซึ่งเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้พิเคราะห์งานประติมากรรมนางรำคู่ที่ปรากฏบนเสาหรือผนังต่าง ๆ จากภาพเพียงบางภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามรูปถ่ายรูปที่ 114 ในสำเนาหนังสือประติมากรรมขอม ของศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ เรียบเรียงจากบทความของศาสตราจารย์ของ และรูปถ่ายรูปที่ 3 ที่ 6 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 12 ที่ 13 ที่ 14 ที่ 15 และที่ 16 แล้ว เห็นว่า งานประติมากรรมนางรำคู่ศิลปะขอมโบราณมีองค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของงานแยกเป็นสามส่วนคือ ส่วนแรก ฐานของนางรำที่เป็นฐานดอกบัว และมีดอกบัวตูมชูช่ออยู่ 2 ดอก ส่วนที่สอง นางรำคู่ที่สวมชฎาซึ่งอยู่ในท่ารำ ยกขาข้างหนึ่งขึ้นสูง และส่วนที่สาม คือ ชุ่มประตู่ที่คลุมนางรำคู่อยู่ องค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้มีลักษณะเหมือนกันกับงานวัตถุพยานหมายเลข 2 ของโจทก์ร่วม ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสาระสำคัญทั้งสามส่วน ได้แก่ ลายเส้นโค้งของชุ่มประตู่ที่มีอยู่ 4 ถึง 5 เส้นก็ดี ลายดอกไม้ 3 ดอก และตำแหน่งของแต่ละดอกระหว่างลายเส้นโค้งของชุ่มประตู่ก็ดี ลายที่อยู่เหนือเส้นโค้งของชุ่มประตู่พร้อมกับลายดอกไม้อีกก็ดี และลักษณะลายผ้าชายไหวชายแครงที่นางรำนุ่ง รวมทั้งชฎาหรือต่างหูที่นางรำสวมใส่ก็ดี ก็เหมือนกันหรือคล้ายกัน ส่วนที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนั้นก็

จะเป็นเพราะต่างกันในเรื่องความชัดเจนตามสภาพความเก่าแก่หรือเสื่อมสลายของงาน ในเรื่องการวางตำแหน่งต่าง ๆ ของรูปและตำแหน่งของลวดลายต่าง ๆ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน โจทก์ร่วมก็เบิกความยอมรับว่า โจทก์ร่วมวาดภาพแม่พิมพ์ของงานดังกล่าวนั้นจากงานขอมโบราณรูปนางอัปสรหรืออัปสร แต่ก็ได้ไม่ได้ นำสืบให้เห็นได้ว่าต้นแบบงานขอมโบราณรูปนางอัปสรหรืออัปสรที่นำมาเป็นแบบตามที่อ้างถึงนั้นมีลักษณะอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้นแบบเป็นงานตามโบราณสถานปราสาทบายนภายในประเทศหรือในประเทศเพื่อนบ้าน การพิเคราะห์ว่าเป็นงานที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงจากต้นแบบงานตามโบราณสถานดังกล่าวหรือไม่ ก็ยังต้องพิเคราะห์ด้วยความระมัดระวังยิ่ง เพราะอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของสาธารณชนที่มีต่องานดังกล่าวหรือความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น ที่โจทก์ร่วมเบิกความว่า โจทก์ร่วมวาดภาพแม่พิมพ์ของงานดังกล่าวโดยวาดรูปแบบ เอกลักษณ์ สัดส่วน รูปทรง ลวดลายใหม่ แตกต่างไปจากงานประติมากรรมรูปนางรำคู่หรือนางอัปสรหรืออัปสรที่ปรากฏที่โบราณสถานโดยไม่เคยเห็นของเก่าดั้งเดิมที่แท้จริงของศิลปะขอมว่าเป็นอย่างไรมาก่อน แต่วาดภาพผสมผสานกับลายกนกบ้าง ลายไทยอื่น ๆ บ้าง เกิดเป็นงานขึ้นมาใหม่ โดยมีเพียงโจทก์ร่วมมาเบิกความลอย ๆ ยืนยันถึงเรื่องนี้จึงไม่น่าเชื่อถือ ทั้งจำเลยยังมีนายชินทร์ นายช่างศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งมีหน้าที่คิดริเริ่มค้นคว้าและสร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรม รวมทั้งซ่อมแซมผลงานวัตถุโบราณที่สึกหรอของประเทศมานาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญมาเบิกความเป็นพยานด้วยว่า โครงร่างของภาพนางรำตามประติมากรรมวัตถุพยานหมายเลข 2 นั้น เป็นศิลปะขอม ดูจากลวดลายแล้วก็เป็นลวดลายศิลปะขอม เครื่องทรงส่วนประกอบของนางรำมีลักษณะเป็นลวดลายศิลปะขอม ส่วนดอกบัวก็เป็นศิลปะขอมเช่นกัน ซึ่งเป็นดอกบัวตูม และแบ่งกลีบออกเป็นชั้น ทรงของดอกบัวจะยาว ผิดแผกไปจากแบบดอกบัวของไทย ส่วนที่เป็นข้มเหนือนางรำทั้งคู่มียลายกนกและลายประจำยาม ซึ่งในส่วนของปลายลายมีลักษณะแข็งไม่สับัดตามลักษณะลายของ

ขอม ซึ่งโดยสรุปลวดลายศิลปกรรมในวัดอุทยานหมาย วจร. 2 ทั้งหมดเป็นลวดลาย
ศิลปะขอม นอกจากนี้โจทก์ร่วมเองก็เบิกความยอมรับว่า ผลงานคล้ายงาน
ประติมากรรมนางรำคู่วัดอุทยานหมาย วจร. 2 นั้น โจทก์ร่วมเห็นมีบุคคลต่าง ๆ ทำ
ขายอยู่มากทั้งที่จังหวัดนครราชสีมาและตลาดนัดสวนจตุจักรและทั่ว ๆ ไปด้วย โดย
เห็นมาตั้งแต่ 5 ถึง 6 ปี ก่อนที่โจทก์ร่วมมาเบิกความในปี 2548 พุทธการณแห่งคดี
จึงมีเหตุให้สงสัยตามสมควรว่า เป็นไปได้ที่โจทก์ร่วมวาดแม่แบบก่อนการแกะแบบ
โดยลอกแบบส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมาจากงานประติมากรรมนางรำคู่ขึ้นใดชิ้นหนึ่งที่
ปรากฏอยู่ที่เสาของโบราณสถานปราสาทบายน จากนั้นจึงทำบล็อกและแกะแบบต่อ
ไปตามลำดับ หรือไม่ก็อาจนำลายที่ลอกจากงานศิลปะที่พบเห็นได้ทั่วไปทั้งที่เป็น
ศิลปะไทยหรือศิลปะขอม ซึ่งสามารถเขียนลอกลายกันได้อย่างง่ายดาย มาเขียน
ลอกลายลงไปในส่วนที่เป็นรายละเอียดของงานประติมากรรมนางรำคู่ที่ปรากฏอยู่ที่
เสาของโบราณสถานปราสาทบายนอีกเพียงเล็กน้อย ซึ่งหากลักษณะการสร้างงาน
ของโจทก์ร่วมเป็นเช่นนั้น ก็ไม่อาจถือได้ว่าการสร้างงานประติมากรรมนางรำคู่ของ
โจทก์ร่วมเป็นการสร้างงานที่มีความคิดริเริ่มด้วยตนเองหรือใช้ความวิริยะอุตสาหะที่
เพียงพอแม้แต่เพียงขั้นเล็กน้อย และเมื่อลักษณะที่ปรากฏของงานที่ออกมาจาก
บล็อกงานหรือแม่แบบของงานตามวัดอุทยานหมาย วจร. 1 อันได้แก่งาน
ประติมากรรมตามวัดอุทยานหมาย วจร. 2 นั้น มีเหตุให้สงสัยตามสมควรว่ามี
ลักษณะที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงมาจากงานประติมากรรมนางรำคู่ตามโบราณสถานดัง
กล่าว แม้การทำซ้ำหรือดัดแปลงจากงานประติมากรรมนางรำคู่ตามโบราณสถานจะ
ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอยู่บ้าง แต่ก็มีความวิริยะอุตสาหะในการทำซ้ำหรือ
ดัดแปลง มิอาจถือเป็นความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานถึงขนาดที่จะได้เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ตามความหมายของกฎหมาย ดังนั้น ไม่ว่าจำเลยจะได้ขายงานที่ทำ
ซ้ำหรือดัดแปลงจากงานประติมากรรมนางรำคู่ตามวัดอุทยานหมาย วจร. 2 หรือไม่
ก็ตาม การกระทำของจำเลยย่อมไม่อาจเป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์

ร่วมไปได้ คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในปัญหาข้ออื่นอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนไป"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(บุญรอด ต้นประเสริฐ-พลรัตน์ ประทุมทาน-รัตน์ กองแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>